

[A-1]

I. 문제의 소재

II. 설문(1)에 대하여

1. 의의 및 취지(법 29조2항)

2. 진보성 판단의 일반적인 순서¹⁾

(1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다.

(2) 인용발명을 특정한다. 복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능하다. 인용발명을 특정할 때에는 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로 통상의 기술자의 시각에서 특정하여야 한다.

(3) 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다. 차이점을 확인할 때에는 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여야 한다. 구체적으로는 발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합되어 있는 것끼리는 구성요소를 분해하지 않고 결합된 일체로서 인용발명의 대응되는 구성요소와 대비한다.

(4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.

3. 용이도출 여부의 판단방법

(1) 일반적 판단방법

(2) 참고적 판단방법

(3) 용이성 판단의 근거²⁾

1) 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것

2) 당업자의 통상의 창장능력의 발휘에 해당하는 것

3) 더 나은 효과

III. 설문(2)에 대하여

1. 선택발명의 진보성 판단방법³⁾

(1) 선택발명의 의의

(2) 진보성 판단방법

1) 심사실무상 공지기술로부터 실험적으로 최적 또는 호적인 것을 선택하는 것은 당업자의 통상의 창장능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않고, 인용발

1) 심사지침서 3303면

2) 심사지침서 3305면

3) 심사지침서 3311면

명에 비하여 더 나은 효과를 가질 경우에 진보성이 인정된다.

2) 판례는 선택발명의 하위개념들 모두가 선행발명의 효과와 질적으로 다른 효과를 갖거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우 진보성을 인정한다(대법원 2001후 2740 판결).

(3) 유리한 효과의 기재방법

판례는 선택발명의 상세한 설명에는 인용발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교 실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 효과가 의심스럽다는 이유로 거절이유가 통지된 때에는 출원인이 비교 실험자료를 제출하는 등의 방법에 의해 그 효과를 구체적으로 주장입증할 수 있다고 한다(대법원 2001후2740 판결).

2. 결합발명의 진보성 판단방법⁴⁾

(1) 결합발명의 의의

(2) 결합발명의 진보성 판단대상

판례는 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이므로, 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 한다(대법원 2005후3277 판결).

(3) 결합발명의 진보성 판단방법

1) 결합발명의 진보성은 2이상의 선행기술을 상호 결합시켜서 판단할 수 있으나, 당업자에게 용이하다고 인정되는 경우에 한한다.

2) 인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단한다.

3) 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 당업자가 용이하게 결합에 이를 수 있는 경우에는 진보성을 부정할 수 있다(대법원 2005후3284 판결)

3. 제법한정물건발명의 진보성 판단방법⁵⁾

(1) 제법한정물건발명의 의의

(2) 제법한정물건발명의 진보성 판단대상

1) 심사실무는 보호받고자 하는 대상은 방법이나 제조장치가 아니라 물건 자체로 해석되므로 진보성에 대한 판단대상은 물건으로 본다. 이 경우 방법적 기재에 의해 물성, 특성, 구조 등을 포함하여 특정되는 물건이 판단의 대상이 된다.

2) 판례는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 물건으로 특정되는 발명만을 그

4) 심사지침서 3315면

5) 심사지침서 3314면

출원전에 공지된 발명과 비교하면 된다고 한다(대법원 2007후449 판결).

3) 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 사정이란, i) 물건 자체가 새로운 것이어서 그 구성을 적절하게 기재하기 어려운 경우, ii) 제조방법에 관한 기재가 물건의 성질이나 구조 등을 간결하게 표현하기 위한 경우 등의 예외적인 경우만을 의미한다(특허법원 2006허7122 판결)

[A-2]

I. 문제의 소재

II. 설문(1)에 대하여

1. 독립항과 종속항의 의의⁶⁾

청구범위에 기재된 청구항은 독립항과 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항으로 구분할 수 있다. 여기서 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한다는 의미는 기술구성을 부가하거나 상위개념을 하위개념으로 한정함으로써 발명을 구체화하는 것을 말하며, 종속항이란 발명의 내용이 다른 항에 종속되어 다른 항의 내용변경에 따라 해당 청구항의 발명의 내용이 변경되는 청구항을 말한다.

2. 독립항과 종속항의 구별기준

(1) 심사실무의 태도

심사실무는 발명의 내용 측면에서는 독립항을 부가하거나 한정하고 있다 하더라도 형식적으로 인용하고 있지 않다면 종속항이라 할 수 없으며, 독립항을 형식적으로는 인용하고 있다 하더라도 독립항을 한정하거나 부가하지 않는 경우에는 종속항이라고 할 수 없다고 한다. 따라서 i) 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재하거나, ii) 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재하는 경우는 독립항으로 취급한다.

(2) 판례의 태도

판례도 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재 형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 독립항으로 보아야 한다고 한다(대법원 2004 후3546 판결)

(3) 인용형식의 기재

독립항은 다른 청구항을 인용하지 않는 형식 즉, 독립형식으로 기재해야 하지만, 독립항이라도 동일한 사항의 중복 기재를 피하기 위하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 형식으로 기재할 수 있다.

III. 설문(2)에 대하여

1. 청구항 1의 경우

다른 청구항을 인용하지 않고 독립형식으로 기재되어 있으므로 독립항.

2. 청구항 2의 경우

(1) '제1항에 있어서'에 따라 청구항 1을 형식적으로 인용하고 있음

(2) 인용되는 청구항 1의 구성요소 '노즐'을 '노즐의 분사구의 형태가 원형인 것'으로 한정하여 구체화하고 있음

6) 심사지침서 2408면

(3) 청구항 1의 상위개념 노즐을 하위개념인 분사구의 형태가 원형인 노즐로 한정하므로써 발명을 구체화 하고 있으므로 종속항.

3. 청구항 3의 경우

(1) '제2항에 있어서'에 따라 청구항 2를 형식적으로 인용하고 있음

(2) 인용되는 청구항 2의 구성요소 '노즐'을 '노즐의 분사구의 형태가 4각형인 것'으로 한정하여 구체화하고 있음

(3) 그러나 청구항 2의 노즐의 분사구의 형태는 원형인 반면, 청구항 3의 노즐의 분사구의 형태는 4각형이고, 원형과 4각형은 상하위개념에 해당하지 않음

(4) 청구항 2의 구성 '분사구의 형태가 원형인 노즐'을 '분사구의 형태가 4각형인 노즐'로 치환하는 형식으로 기재하고 있으므로 독립항.

4. 청구항 4의 경우

(1) '제1항에 있어서'에 따라 청구항 1을 형식적으로 인용하고 있음

(2) 인용되는 청구항 1의 구성요소 '노즐'을 '노즐이 하나인 것'으로 한정하여 구체화하고 있음

(3) 그러나 청구항 1의 노즐은 복수 개인 반면, 청구항 4의 노즐은 하나이고, 복수 개와 하나는 다른 구성임

(4) 청구항 1의 구성 '복수 개의 노즐'을 '하나의 노즐'로 치환하는 형식으로 기재하고 있으므로 독립항.

IV. 설문(3)에 대하여

1. 독립항과 종속항의 진보성 판단방법

2. 청구항 1 내지 4의 진보성 판단의 상호관계

(1) 청구항 1과 청구항 2의 상호관계

1) 청구항 1이 진보성이 있는 경우

독립항인 청구항 1의 잉크 카트리지가 진보성이 있는 경우 종속항인 청구항 2의 잉크 카트리지도 당연히 진보성이 인정된다.

2) 청구항 1이 진보성이 없는 경우

독립항인 청구항 1의 잉크 카트리지가 진보성이 없는 경우 종속항인 청구항 2의 잉크 카트리지의 진보성은 개별적으로 판단해야 한다. 이 경우 청구항 1에 비해 한정된 '분사구의 형태가 원형인 노즐'에 관한 기술 구성을 용이하게 발명할 수 없다면 진보성이 인정될 수 있다.

(2) 청구항 1, 청구항 3 및 청구항 4의 상호관계

1) 청구항 1의 진보성 유무

청구항 1, 청구항 3 및 청구항 4간에는 독립항·종속항의 관계가 성립하지 않으므로 청구항 1의 진보성 유무는 청구항 3 및 청구항 4의 진보성 유무와 무관하다.

2) 독립적으로 판단

독립항인 청구항 1의 잉크 카트리지가 진보성이 없는 경우에도 청구항 3의 ‘분사구의 형태가 4각형인 노즐’에 관한 기술 구성을 용이하게 발명할 수 없다면 진보성이 인정될 수 있다. 마찬가지로 청구항 4의 ‘하나의 노즐’에 관한 기술 구성을 용이하게 발명할 수 없다면 진보성이 인정될 수 있다.

[B-1]

I. 문제의 소재

II. 설문(1)에 대하여

1. 특허를 받을 수 있는 권리 존부

을은 제조방법 K의 발명자는 아니지만, 발명자인 정으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 정당한 승계인이므로 제33조 위반에 해당하지 않는다.

2. 신규성 위반 여부

(1) 갑의 특허로부터 판단

1) 갑의 특허권의 최초명세서에는 $a+b+c$ 물건의 생산 방법이 기재되어 있고, 갑의 특허출원의 출원공개가 2009.6.1 이전에 이루어 졌다면 제29조제1항제2호의 공지기술에 해당한다.

2) $a+b+c$ 물건의 제조방법 K가 갑의 $a+b+c$ 물건 특허와 표현 양식에 따른 차이가 있음에 불과하여 실질적으로 동일한 경우 또는 갑의 특허권의 최초명세서에 기재된 $a+b+c$ 물건의 생산 방법과 동일하다면 신규성 위반에 해당한다.

(2) 정의 공지행위로부터 판단

1) 정이 2009.5.2 제조방법 K에 관한 논문을 발표하여 불특정인이 알거나 볼 수 있게 되었으므로 제29조제1항제1호 또는 제2호의 공지기술에 해당한다.

2) 정의 공지행위로 인한 신규성 위반여부는 공지에외 적용대상의 적법 여부에 따라 달라지므로 이하에서 후술한다.

3. 진보성 위반 여부

제조방법 K가 갑의 특허권의 최초명세서에 기재된 $a+b+c$ 물건의 생산 방법으로부터 용이하게 도출될 수 있다면 진보성 위반에 해당한다.

4. 선출원주의 위반 여부

$a+b+c$ 물건의 제조방법 K가 갑의 $a+b+c$ 물건 특허와 표현 양식에 따른 차이가 있음에 불과하여 실질적으로 동일한 경우 선출원주의 위반에 해당한다.

5. 공지에외 적용대상의 적법 여부

(1) 의의 및 요건

을은 공지일인 2009.5.2부터 6월 내인 2009.6.1 특허출원하였으므로 제30조제1항의 요건은 만족한다.

(2) 제3자의 공개행위

공개자와 출원인이 다른 경우에도 그에 관한 입증서류를 제출하는 경우 공지에외 적용대상을 주장할 수 있다.

(3) 취지 기재의 보정 가부

1) 최근 공지일부터 6월 내에 제30조제2항의 취지기재의 보정을 인정한 특허법원 판결이 있었으나, 대법원은 제30조제2항의 취지 및 공지에외주장은 출원과는

별개 절차인 점을 고려하여 상기 판결을 파기환송하고, 법문에 따라 보정이 허용되지 않음을 명확히 하였다.

2) 을은 공지일부터 6월 내인 2009.6.5에 취지를 기재하고 증명서류를 제출하였으나 판례의 태도에 따라 취지 기재의 보정은 허용되지 않는다.

(4) 소결

을의 공지에외 적용대상 주장은 부적법하므로 정의 공지행위로 인해 신규성 위반에 해당한다.

6. 설문(1)의 해결

III. 설문(2)에 대하여

1. 심판 청구의 적법 여부

(1) 주체적·시기적 요건

특허권자인 갑이 특허권이 유효하게 존속 중에 청구하였으므로 적법하다.

(2) 권리범위확인심판의 대상

판례는 권리범위확인심판은 권리확정을 위한 것으로 보며, 간접침해 여부도 권리범위확인심판의 판단대상이라고 본다.

(3) 확인대상발명의 특정

1) 심판청구인은 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여 확인대상발명을 특정해야 하며(법 140조3항) 판례는 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정해야 한다고 한다.

2) 간접침해의 경우 판례는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 확인대상발명으로 특정하여 권리범위확인을 구할 수 있다고 한다.

3) 갑이 a+b의 반제품을 구체적으로 특정하였다면 확인대상발명의 특정은 적법하다.

(4) 소결

2. 주장의 인용 여부

(1) 직접침해 여부

(2) 간접침해 여부

1) 의의 및 취지

2) 물건발명의 간접침해행위

3) 공용성

가) 공용성이란 간접침해품이 특허 물건의 생산에 사용되는 것을 의미한다.

나) 판례는 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 본다(대법원 2007후3356판결).

다) a+b의 반제품은 a+b+c의 특허물건의 일부 구성요소와 대응하고, a+b의

반제품에 제조방법 K를 적용하여 $a+b+c$ 의 물건을 생산할 수 있어 공용성이 인정된다.

4) 전용성

가) 전용성이란 타용도가 없다는 것을 의미하며, 판례는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 타용도가 없어야 한다고 본다.

나) 전용성은 특허권자가 입증해야 하며, 권리범위확인심판의 경우 심결시를 기준으로 판단한다.

다) $a+b$ 의 반제품은 $a+b+c$ 물건을 생산하는 용도 외의 용도는 없으므로 이와 같은 사실을 같이 입증하는 경우 전용성이 인정된다.

(3) 소결

[B-2]

I. 문제의 소재⁷⁾

II. 설문(1)에 대하여

1. 특허법상 공동심판

동일한 특허권에 관하여 무효심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 공동으로 심판을 청구할 수 있다(법 139조1항).

2. 심결취소소송의 성격

(1) 문제점

공동심판의 심결취소소송이 고유필수적 공동소송은 아니므로 공동심판 청구인 중 1인이 제기한 소나 1인에 대하여 제기한 소는 적법하다. 다만, 유사필수적 공동소송으로 볼지 통상공동소송으로 볼지에 따라 나머지 공동심판 청구인에 대한 관계에서 무효심결이 확정되어 소의 이익이 없어지는지 또는 일사부재리에 저촉되는지 문제된다.

(2) 견해의 대립

1) 특허법상 공동심판은 유사필수적 공동심판이고, 그 심결취소소송도 유사필수적 공동소송의 성격을 가져, 1인이라도 심결취소소송을 제기하면 심결은 확정되지 않고, 승소 확정판결에 의해 심판이 계속되면 나머지 공동심판 청구인도 다시 청구인으로서의 지위를 유지한다고 보는 유사필수적 공동소송설.

2) 특허법상 공동심판은 심판관의 재량으로 분리심결이 가능하고, 반드시 합일확정이 필요한 것도 아니므로 통상공동심판이고, 그 심결취소소송도 통상공동소송으로 보아, 심결후 공동심판 청구인별로 분리확정될 수 있다는 통상공동소송설

(3) 판례의 태도

특허법원의 판례 중에는 유사필수적 공동소송설의 입장을 취한 것과 통상공동소송설의 입장을 취한 것이 있으나, 최근 대법원은 특허법상 공동심판은 유사필수적 공동심판에 해당하고 공동심판 청구인 중 1인만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 모두 확정이 차단되며, 다른 공동심판 청구인에 대한 부분만이 분리확정되었다고 할 수 없다고 하여 유사필수적 공동소송설의 입장이다(대법원 2007후1510 판결).

(4) 검토

생각건대, 심판관의 재량적 취급에 따라 유사필수적 공동소송이 되기도 하고 통상공동소송이 되기도 하는 것은 불합리하므로 유사필수적 공동소송설이 타당하다.

III. 설문(2)에 대하여

7) 지적재산소송실무 개정2판 20면

1. 소 제기의 적법성

(1) 유사필수적 공동소송설

전체 심결의 확정이 차단되므로 다른 공동심판 청구인에 대한 관계에서 심결이 확정된다거나 이로 인해 소의 이익 상실 문제도 발생하지 않고, 심결이 취소되는 경우 다른 공동심판청구인은 다시 심판절차에 당사자로서 참여할 수 있으며, 심결취소소송이 패소 확정되면 그 때 비로소 심결이 확정된다.

(2) 통상공동소송설

심결취소소를 제기하지 않은 공동심판청구인에 대한 관계에서 심결이 분리확정되고 되고, 특허권은 확정적으로 무효로 되므로, 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어져 심결취소소는 각하된다.

2. 당사자 적격

(1) 원고 적격

1) 원고 적격의 제한(법 186조2항)

2) A는 공동심판의 당사자로서, 인용심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 있어 원고적격을 가진다.

(2) 피고 적격

1) 피고 적격의 법정(법 187조)

2) 같은 공동심판 청구인으로서 피고적격을 가진다.

3. 당사자 추가 방법

판례는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로 나머지 공동심판 청구인을 피고로 추가하는 신청은 당사자의 변경을 가져오는 것으로서 허용될 수 없다고 한다(대법원 2007후1510 판결).

IV. 설문(3)에 대하여

1. 소제기의 적법성

(1) 유사필수적 공동소송설

전체 심결의 확정이 차단되므로, 확정심결에 인정되는 일사부재리는 문제되지 않고, 심결취소소송에서 패소 확정되면 그때 비로소 심결이 확정된다.

(2) 통상공동소송설

나머지 공동심판 청구인에 대한 관계에서 심결이 분리확정되게 되고, 일사부재리의 판단시점을 심결시로 보는 판례에 따라 심결취소소송은 분리확정된 심결의 일사부재리에 저촉되는 것은 아닌지 문제되나, 법관에 의한 재판을 받을 권리에 대한 중대한 침해가 될 수 있다는 점에서 허용함이 타당하다.

2. 당사자 적격

(1) 원고 적격

같은 공동심판의 당사자로서, 기각심결의 취소를 구할 법률상 이익이 있어 원고 적격을 가진다.

(2) 피고 적격

A는 공동심판의 피청구인으로서 피고 적격을 가진다.

3. 당사자 추가 방법

다른 공동심판청구인도 심결취소소송을 제기하려는 경우 제소기간 내라면 공동소송참가를 하면 되고, 별도로 소를 제기하면 특허법원은 변론을 병합하여 공동소송으로 심리하게 되며, 제소기간이 경과된 경우에는 공동소송참가도 할 수 없고 보조참가를 할 수 있을 뿐이다.